

1501339-26.2021.8.26.0537

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

Comarca: Diadema

Foro: Foro de Diadema

Vara: 2ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 12/01/2022

... em dinheiro. Acha que o réu confirmou o tráfico e não o tinha visto lá antes, pois uma rua para cima existe um ponto de tráfico já conhecido.

Neste sentido foi o depoimento do miliciano Rogério Carneiro confirmou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu que ao ver a equipe correu e entrou na rua Grécia, dispensando uma pochete próximo a um veículo. Detido por ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Diadema

Foro de Diadema

2ª Vara Criminal

Avenida Sete de Setembro, 399, Diadema-SP - cep 09912-010

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 1501339-26.2021.8.26.0537 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501339-26.2021.8.26.0537

Classe - Assunto:

Auto de Prisão em Flagrante - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial - 2181871/2021 - 03º D.P. DIADEMA

Autor:

Justiça Pública

Indiciado:

Ryan Paiva da Silva

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Patrícia Helena Hehl Forjaz de Toledo

VISTOS.

RYAN PAIVA DA SILVA, qualificado à fl. 15, está sendo processado como incurso no artigo 33, "caput", da Lei nº 11.343/06 c.c. art. 61, II, alínea j, do Código Penal, porque no dia 06 de julho de 2021, por volta das 07h30, na Rua Grécia, n.º 80, bairro Taboão, nesta cidade e comarca de Diadema trazia consigo, para fins de entrega a consumo de terceiros, 40 invólucros plásticos contendo cocaína, com peso aproximado de 27,3 gramas, 39 invólucros plásticos contendo cocaína na forma de crack, com peso aproximado de 9,7 gramas e 74 invólucros plásticos contendo Cannabis sativa L, vulgarmente conhecida como "maconha", com peso aproximado de 244,0 gramas, substâncias entorpecentes causadoras de dependência física e psíquica, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar,

conforme auto de exibição e apreensão de fl. 17 e laudo de constatação provisória de fls. 21/24.

Convertida a prisão em flagrante em preventiva (fl. 48/51), a denúncia foi recebida em 18/10/2021 (fl.125/126), sem proposta de transação penal. Seguiu-se com a notificação e citação do réu, a quem foi nomeado Defensor Público que ofertou defesa inicial as fls. 115/117.

Em audiência uma foram ouvidas as testemunhas arroladas pelas Partes, e interrogado o réu ao final, seguindo-se com os debates orais.

Nestes, o Órgão Ministerial requereu a procedência parcial da ação por provadas autorias e materialidade delitivas, entendendo que a pena base deva ser fixada acima do mínimo legal diante da excessiva quantidade e variedade de drogas altamente nocivas como o crack e cocaína, afastando-se a agravante da calamidade pública, com as duas atenuantes e a redução mínima da pena, mas não também sua substituição por restritivas de direitos, devendo ser cumprida em regime intermediário, sem possibilidade de apelo em liberdade, com a perda do numerário apreendido.

Já a d. Defensor Público pretendeu a absolvição do acusado ante a fragilidade probatória. Subsidiariamente, requereu que a pena-base fosse fixada no mínimo legal, com as atenuantes da confissão e da menoridade relativa, fixando-se regime mais brando e substituição da pena corporal pela restritiva de direitos, com direito de apelo em liberdade até pela detração penal. É o breve relatório.

Passo a fundamentar e decidir.

A ação procede em parte, por ser hipótese de se afastar a agravante da calamidade pública da pandemia da Covid19 ao caso em tela por falta de prova do nexa causal. No mais, é caso de condenação. Vejamos.

A materialidade delitiva vem no auto de exibição e apreensão de fls.21, laudos de constatação e definitivo, ambos positivos para as drogas maconha e cocaína (respectivamente às fls. 25/28 e 165/167) além da apreensão de numerário proveniente da mercancia ilícita (R\$ 65,00 - fl. 67).

A autoria é inconteste conforme prova que sigo analisando.

Os policiais militares afirmaram em solo pré-processual (fls.11 e 12) que realizaram patrulhamento na região, especificamente na rua Grécia, altura do nº 80, quando avistaram um indivíduo em atitude suspeita, parecendo esconder entorpecentes, razão pela qual decidiram iniciar os procedimentos de abordagem. No momento que em que o indivíduo os avistou, jogou uma pochete no chão e tentou correr, sendo capturado logo em seguida. Na pochete jogada ao chão foram encontrados 74 invólucros de substância semelhante à maconha, 40 invólucros de substância semelhante à cocaína e 39 invólucros de substância semelhante à crack, além da importância de R\$65,00 em dinheiro.

Em juízo o policial César de Albuquerque reiterou que estavam em patrulhamento pela rua Portugal, cruzamento com a rua Grécia. O réu os viu e correu, jogando um objeto ao solo. Nada foi encontrado com o acusado, mas o objeto que ele dispensou estava perto dele. Era uma pochete, e continha entorpecentes, cerca de uns setenta de maconha, cinquenta de cocaína e quarenta de crack, além de R\$65,00 em dinheiro. Acha que o réu confirmou o tráfico e não o tinha visto lá antes, pois uma rua para cima existe um ponto de tráfico já conhecido.

Neste sentido foi o depoimento do miliciano Rogério Carneiro confirmou que estavam em patrulhamento quando avistaram o réu que ao ver a equipe correu e entrou na rua Grécia, dispensando uma pochete próximo a um veículo. Detido por seu parceiro, foi

até o local onde ele dispensou a pochete contendo as drogas e dinheiro, cerca de sessenta e cinco reais. O local é próximo de uma biqueira e foi a primeira vez que viu o réu, pois não o conhecia até então. Ao lembra o que o réu disse sobre as drogas.

O réu, extrajudicialmente (fl.13), confessou que estava no local com as substâncias e o valor apreendido.

Sob o crivo do contraditório o acusado confessa que estava traficando e correu quando viu a patrulha, mas na rua de cima tinha mais policiais e foi abordado, sendo que antes já havia dispensado a pochete com as drogas e o dinheiro da venda delas, perto de um carro, onde eles a acharam, estando arrependido, confirmando já ter duas passagens pelo mesmo artigo quando adolescente.

Logo, o interrogatório com a confissão do réu não é prova única, pois veio corroborada pelos depoimentos dos testemunhos policiais - que são válidos e eficazes para a convicção condenatória, até por não haver dúvidas sobre sua lisura - estão em consonância com os demais elementos probatórios contidos nos autos, sendo corroborados pelo auto de apreensão e exibição, além das provas periciais, sem outra prova contrária ao coeso contexto probatório.

Ademais, é cediço que no crime de tráfico de drogas, em regra, a prova é baseada nos depoimentos dos policiais, e na presente hipótese ainda tem-se a confissão do réu, além do que a defesa não apresentou nenhuma prova concreta capaz de ilidir as declarações dos milicianos, não havendo motivo plausível para seu desmerecimento, consoante Enunciado 70 da Súmula de Jurisprudência do STJ.

Ainda que não presenciado qualquer ato de comércio, as circunstâncias do flagrante demonstram a conduta prevista no art. 33, caput, da Lei de Drogas, que consigna como verbos nucleares trazer consigo, conduta perpetrada pelo réu, comprovada a circulabilidade. O tráfico de drogas é crime de ação múltipla e a prática de um dos verbos contidos no art. 33, caput, é suficiente para a consumação da infração, sendo prescindível a realização de atos de venda do entorpecente.

À luz do art. 28, § 2º, da Lei 11.343/06, a natureza da droga (cocaina), o local da prisão (um ponto de venda de drogas conhecido), o numerário apreendido (fl. 67), são fatores que, reunidos, permitem a conclusão indubitável de que o elemento subjetivo do agente dirigia-se especificamente à mercancia e não ao mero consumo pessoal, de modo que a procedência do pedido é inarredável.

Passa-se, pois, à dosimetria da pena.

Observado o art. 59 do Código Penal, os motivos, circunstâncias e consequências do delito, as pela excessiva quantidade de narcótico apreendido (153 involucros no total), às vistas do disposto no art. 42 da Lei de Drogas, fixo em primeira fase, a pena base acima do mínimo, qual seja, 05 anos e 10 meses de reclusão e 583 dias-multa.

Em segunda fase, não há circunstâncias agravantes a serem consideradas, e sim as atenuante da confissão e da menoridade relativa (fl. 15), a reduzir as penas ao mínimo legal: 05 anos de reclusão e 500 dias-multa.

Quanto à citada na exordial, do art. 61, II, "j", do CP, embora os fatos tenham se dado em época da pandemia pelo Covid 19, entendo não haver prova cabal de que o agente tenha se aproveitado, de modo consciente e voluntário, dessa situação especial à prática delitiva, ou que tenha se valido da facilidade que dela decorreu como: dificuldade de policiamento, menor cuidado por parte da vítima ou uma situação dramática pela qual passasse, incapacitando-a total ou parcialmente de defesa, por estar fragilizada ou adoentada, a merecer maior grau de reprovabilidade

da conduta, dada a ausência de solidariedade humana e frieza moral. Ademais, não houve invasão da esfera de individualidade de terceira pessoa. Neste sentido vide: Por unanimidade, a 1ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo afastou a agravante de crime cometido em período de calamidade pública, conforme o artigo 61, inciso II, alínea j, do Código Penal, pois, segundo o relator, desembargador Andrade Sampaio, "não restou devidamente comprovado nos autos que o réu se aproveitou das circunstâncias de fragilidade, vulnerabilidade ou incapacidade geradas pelo estado de calamidade pública decretado em virtude da pandemia da Covid-19" (TJ-SP / Proc. 1512067-20.2020.8.26.0228).

Em terceira etapa, não concorrem causas de aumento nem de redução de pena, pois embora seja o acusado primário, ostenta medidas sócio educativas (fls. 29/30 e 89/97) inclusive pela prática de crime análogo, praticado em data próxima a desses autos, indicando seu maior envolvimento com a traficância ilícita, e sua dedicação ao crime. Tanto que estava em poder de dinheiro proveniente do tráfico, demonstrativo de vendas efetivamente feitas à usuários, disseminando o vício entre eles, somado à presença do crack, de alto poder viciante e degradante do ser humano impactando negativamente na sociedade, tudo a indicar seu envolvimento maior com a mercancia ilícita e integrar organização criminosas, e a justificar o percentual de redução mínimo, de 1/3, como quer o MP, totalizando 03 anos e 04 meses de reclusão e 333 dias-multa.

Neste sentido vide: Apelação. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Recurso da defesa. PRELIMINAR. 1. Alegação de nulidade do interrogatório do acusado, por ter sido inquirido antes da colheita dos depoimentos das testemunhas. Ausência de impugnação quando da realização do ato. Não comprovação de prejuízo. Preliminar rejeitada. MÉRITO. 1. Conjunto probatório a evidenciar a responsabilidade do apelante pelo crime de tráfico de drogas. 2. Inaplicabilidade da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. A prática de ato infracional equivalente ao tráfico de drogas pode ser considerada como dado a obstar a aplicação da minorante prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei nº 11.343/06. Precedentes do STJ. 3. Sanção que não comporta reparo. Recurso improvido." (TJSP; Apelação Criminal 1500078-39.2018.8.26.0599; Relator (a): Laerte Marrone; Órgão Julgador: 14ª Câmara de Direito Criminal; Foro de Piracicaba - 2ª Vara Criminal; Data do Julgamento: 27/06/2019; Data de Registro: 01/07/2019) - grifo nosso.

Fixo o regime prisional semiaberto por conta da grande quantidade e variedade das drogas, mostrando-se razoável, ainda, diante da reiteração criminosa do agente. Segundo entendimento do STJ já firmado, nos delitos previstos na Lei de Drogas, a fixação do regime prisional deve observar a regra do artigo 33, parágrafo 2º, do Código Penal, em conjunto com o artigo 42 da Lei 11.343/2006, que determina a consideração, preponderantemente, da natureza e da quantidade da droga. Assim, fixo regime inicial mais gravoso do que aquele relacionado unicamente com o quantum da pena ao considerar tais circunstâncias, no caso em tela 153 invólucros entre maconha, cocaína e crack, além da apreensão de dinheiro (fl. 67) a justificar não fixação do regime mais brando como quer a Defesa. Conforme entendimento jurisprudencial consolidado nesta Corte, não constitui bis in idem a utilização do fundamento com base na quantidade expressiva de droga apreendida para elevar a pena-base e, também, para estabelecer o regime prisional." (AgInt no REsp 1.539.980/PR, j. 11/04/2019).

Incabível a benesse do art. 44 do CP ao réu, pela excessiva quantidade de substâncias entorpecentes e por sua natureza de alto poder viciante (do crack e cocaína), não se mostrando socialmente recomendável por se tratar de ação de extrema gravidade.

Some-se a isso o fato de que : ... O artigo 44, caput, da Lei de Drogas veda, expressamente, a substituição de pena privativa de liberdade por restritiva de

direitos para o condenado pelos crimes previstos nos artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37. Já o artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas, que prevê uma causa de diminuição de pena, também estabelece, no caso de sua aplicação, que a pena privativa de liberdade não poderá ser substituída por restritiva de direitos. Ainda, a 5ª Turma do Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento de não ser possível a aludida substituição para o condenado por tráfico de drogas e condutas correlatas (artigos 33, caput e parágrafo 1º, e 34 a 37), bem como quando da aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, parágrafo 4º, da Lei de Drogas (HC 144.915/MG, Rel. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010. No mesmo sentido – STJ – HC 136.618/MG, 5ª t., Rel. Min. Laurita Vaz, v.u., j. 01.06.2010). ... Ora, não nos parece razoável proceder a substituição para autor de crime de suma gravidade. A personalidade, a conduta social e culpabilidade do traficante de drogas e de quem de qualquer forma o auxilia, bem como as consequências do crime, que são nefastas para o viciado e usuário e para a sociedade, não recomendam a substituição, que pode ser indeferida nos termos do artigo 44, III, do Código Penal. Ressalte-se, por fim, que a droga é o câncer que assola a todo o mundo já que, direta ou indiretamente, é responsável por boa parte dos crimes violentos que o afligem. Por causa dela as pessoas matam ou são mortas. É muito difícil um crime violento não ter a droga como estopim. Ou o agente está sob seu efeito, ou é vítima de um traficante ou de um drogado, ou é um traficante que mata um rival etc. Enfim, a droga, de uma maneira ou de outra, está ligada aos crimes mais graves

Vedo o recurso em liberdade, sendo incongruente soltar o réu, ora condenado a regime que o manterá preso para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, permanecendo inalteradas as circunstâncias fáticas e jurídicas que justificaram a decretação da prisão preventiva. (...) Não há lógica em permitir que o réu, preso (...) durante toda a instrução criminal, aguarde em liberdade o trânsito em julgado da causa, se mantidos os motivos da segregação cautelar (...) (STF HC nº 89.824/MS Rel. Ministro Ayres Britto Dj. 28.08.2008; STJ RHC nº 111.421/RJ, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, j. 03.10.2019, DJe 10.10.2019; RHC nº 118.468/MG, Relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, j. 17.10.2019, DJe 25.10.2019; RHC nº 34.998/RJ Rel. Ministro Jorge Mussi Dj. 20.03.2013).

Deixo de me manifestar sobre a detração penal, parecendo mais adequado que o juízo da execução se manifeste por primeiro, observando-se também o princípio constitucional do duplo grau de jurisdição, da individualização da pena e do juiz natural. Não bastasse isso, progressão de regime é matéria a ser apreciada pelo juiz da execução, competente para tanto, nos moldes do art. 112 da LEP, caso contrário, o preso provisório obteria um benefício sem se verificar, primeiramente, se preenche os requisitos da referida Lei especial, que prevalece sobre a geral. Inclusive, o réu está preso há menos de três meses, e sem direito sequer à progressão de regime, considerando a prisão do réu por menos de sete meses.

Neste sentido, posicionamento do E. Superior Tribunal de Justiça: A previsão inserida no § 2.º do art. 387 do Código de Processo Penal, não se refere à verificação dos requisitos para a progressão de regime, instituto que se restringe à execução penal, mas da possibilidade de o Juízo de 1.º Grau, no momento oportuno da prolação da sentença, estabelecer regime inicial mais brando, em razão da detração. Ainda que realizado o desconto do quantum da pena, do período em que o réu se manteve em custódia preventiva, não há óbice de que o magistrado fixe regime inicial mais gravoso, fundamentando-se nas circunstâncias do caso concreto, que recomendam maior rigor no cumprimento da pena (STJ, 5.ª Turma, HC n.º 361092/SP, rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 05/11/2015, grifei). Raciocinar em sentido contrário seria admitir uma espécie de “progressão de regime” pelo juízo criminal (que não tem competência para tanto), sem a análise dos requisitos objetivos e subjetivos estabelecidos pela Lei de Execuções Penais.

Por fim, não há valor mínimo de reparação do dano a ser arbitrado.

DISPOSITIVO.

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE A PRESENTE AÇÃO contra RYAN PAIVA DA SILVA, qualificado à fl. 15, como incurso apenas no artigo 33 "caput" da Lei n.º 11.343/06, e o faço para condená-lo à pena de 03 anos e 04 meses de reclusão, em regime inicial semiaberto, mais ao pagamento de 333 dias-multa, cada qual fixado em 1/30 do valor do salário mínimo a época dos fatos, corrigido monetariamente à data do efetivo pagamento.

Absolvo o réu RYAN PAIVA DA SILVA das penas do art. 61, II, j, do CP, com fulcro no art. 386, VII, do CPP.

O condenado não poderá apelar em liberdade. Recomendo-o no cárcere compatível com o regime ora fixado.

Sem condenação ao pagamento das custas e despesas processuais ante a assistência pela DPE.

Decreto a perda de bem e valores apreendidos nestes autos (fl. 67), com fulcro no art. 63 da Lei 11.343/06. E determino a destruição de todas as drogas.

Com o trânsito em julgado desta sentença, opere-se a detração penal, certifique-se e extraia-se a guia de recolhimento definitiva em relação à pena corporal, encaminhando-se à V.E.C. competente, certifique-se o cálculo da pena de multa, intime-se o réu a paga-la em 10 dias sob as pena da lei.

Oficie-se ao Senad, ao IIRGD e TRE.

Publicada em audiência, saem os presentes cientes e intimados. Cumpra-se.

Diadema, 12 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA